

1501832-11.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (certidões a fls. 124/131) e responde a outra ação penal por tráfico de drogas e, por ocasião do fato, fruía a liberdade provisória concedida em 05/11/2021, deixando claro que se dedica a atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501832-11.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001337

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323140/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO HENRIQUE FISCHER

Réu Preso

Aos 08 de março de 2022, às 14:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. ANTONIO CARLOS PEREZ ANTUNES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: GUSTAVO HENRIQUE FISCHER - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor constituído: Dr. LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM WELLINGTON TADEU STANCOV - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM RAFAEL PEREIRA DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha da Defesa: DAIANA PIRES DE OLIVEIRA - AUSENTE (Substituída por declarações, fls. 197)

Testemunha da Defesa: ISAIAS DE OLIVEIRA - AUSENTE (Substituída por declarações, fls. 197)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PM WELLINGTON TADEU STANCOV.

Dada a palavra ao Dr. Promotor, por ele foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM RAFAEL PEREIRA DA SILVA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu GUSTAVO HENRIQUE FISCHER foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "GUSTAVO HENRIQUE FISCHER, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 08h28m, na Rua Uvaíias, nº 175, Bosque dos Lenheiros, Bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca de Piracicaba, tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 38 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 87,6g, 76 Eppendorfs de cocaína na forma de "crack", com peso bruto aproximado de 65,5g, 10 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 14g, 01 porção (pedra) de cocaína da forma de "crack", com peso bruto aproximado de 39,8g, e mais 4 tijolos de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 2200g e 155 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 840g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 107/109) O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. O réu em seu interrogatório disse que estava guardando drogas porque devia drogas para traficantes. Estava devendo R\$ 500,00. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo laudo definitivo a fls. 192/196 e fotografias de fls. 14/15. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o policial Wellington relatou, na fase informativa (fls. 04), que "estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina quando foram acionados, via COPOM, para averiguar denúncia dando conta de que drogas estariam sendo armazenadas no forro da residência existente no local dos fatos, tudo sob a responsabilidade da pessoa de prenome GUSTAVO. Que, devidamente autorizados pelo morador, Sr. Sérgio Fischer, os policiais militares ingressaram no imóvel. Que, após a devida busca domiciliar, lograram localizar, no quarto do filho de Sérgio, GUSTAVO HENRIQUE FISCHER, uma sacola em cujo interior havia 38 porções de substância semelhante à MACONHA; 76 'pinos' contendo aparentemente CRACK e outros 10, contendo, a princípio, COCAÍNA; e, ainda, 1 outra porção ('pedra') aparentemente de CRACK. Que, após buscas no forro da edificação, lá encontraram mais 4 'tijolos' e 155 porções aparentando serem de MACONHA; e, ainda, diversos petrechos empregados no tráfico de drogas (balança de precisão; 3 sacos fechados e outros 2 abertos contendo 'eppendorfs' plásticos vazios)". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que a informação do Copom dava conta de que no local estariam sendo guardadas várias drogas no forro e no quarto do réu. Assim, a confissão do réu, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de petrechos, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. Neste panorama, devidamente demonstradas materialidade e autoria delitivas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu não ostenta antecedentes (certidões a fls. 111/112), mas a grande quantidade de drogas autoriza a majoração da pena-base. Ele já cumpriu medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (certidões a fls. 124/131) e responde a outra ação penal por tráfico de drogas e, por ocasião do fato, fruía a liberdade provisória concedida em 05/11/2021, deixando claro que se dedica a atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como

pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada".

Pela Defesa foram apresentadas alegações finais, as quais foram gravadas através do sistema de mídia digital, disponibilizadas estas no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE FISCHER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 08h28min, na Rua Uvaías, nº 175, Bosque dos Lenheiros, Bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca de Piracicaba, tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 38 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 87,6g, 76 "eppendorfs" de cocaína na forma de "crack", com peso bruto aproximado de 65,5g, 10 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 14g, 01 porção (pedra) de cocaína na forma de "crack", com peso bruto aproximado de 39,8g, 04 tijolos de Cannabis sativa L, com peso aproximado de 2.220g, e 155 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 840g (oitocentos e quarenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares receberam informações de que o acusado armazenava entorpecentes no local dos fatos, para onde seguiram em diligência. Após adentrarem no imóvel, localizaram, no quarto de GUSTAVO, 38 porções de maconha, 76 porções de "crack", 10 porções de cocaína e 01 pedra de "crack" acondicionados em uma sacola. Ato contínuo, no forro do imóvel, foram localizados mais 04 tijolos de maconha e outras 155 porções da mesma droga, além de 03 sacos fechados e outros 02 abertos contendo "eppendorfs" plásticos vazios e uma balança de precisão, materiais destinados ao embalo de entorpecentes.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 184) e apresentou defesa preliminar (fls. 137/139), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia em 13.12.2021 (fls. 147/149).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia.

Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. Consigno, de início, que a Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, como aquele em que há o flagrante delito, dispondo, em seu art. 5º, inciso XI, que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Os policiais receberam informação, com riqueza de detalhes, de que o réu armazenava grande quantidade de entorpecentes em sua residência, razão pela qual para lá se dirigiram. Atestaram que cientificaram o genitor do réu da denúncia, tendo ele afirmado que nada havia em sua residência, autorizando a entrada da equipe.

Logo, havia, em tese, situação de flagrante delito e os policiais atestaram que foram autorizados pelo morador a fazer buscas no local, não sendo o fato infirmado por nenhum elemento de prova.

Não obstante, considerando que os policiais militares reduzem a termos suas diligências, determino seja requisitada a vinda do BOPM, para que fique juntado aos autos.

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.

12/13, pelas fotografias de fls. 14/15 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 192/196, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha. A autoria também é certa.

Na fase policial, o acusado admitiu a propriedade dos entorpecentes e negou a traficância. Narrou que, na data e horário dos fatos, estava em sua residência quando foi surpreendido pela presença dos policiais, cuja entrada foi supostamente autorizada pelo seu genitor. Alegou que os entorpecentes localizados lhe pertenciam e se destinavam ao consumo próprio.

Em juízo, disse que estava guardando a droga e recebia R\$ 300,00 por semana. Asseverou que guardava para o "Cabelo" porque passava necessidades. Disse que estava devendo R\$ 500,00 para o tráfico e fazia três dias que estava guardando a droga para pagar a dívida. Alegou que seu pai não deixou os policiais entrarem e eles não apresentaram mandado. Aduziu que usa maconha porque tem convulsão e fica mais calmo. Informou que estão faltando remédios no CDP.

O policial militar Wellington relatou que receberam informação, via COPOM, de que um rapaz estaria na posse de grande quantidade de entorpecentes na casa. Disse que foram ao local e se depararam com o pai do acusado, que, de pronto, falou que não tinha nada na casa e, se quisessem, poderiam entrar para ver. Atestou que ingressaram na residência e, como havia sido noticiado pelo solicitante, encontraram grande quantidade de entorpecentes no forro da casa e uma pequena quantidade de drogas no quarto do réu. Aduziu que o réu admitiu a propriedade da droga, mas não falou nada sobre sua destinação.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Rafael, ouvido a fls. 04.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais militares não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais terem recebido denúncia anônima dando conta que um rapaz chamado Gustavo estava armazenando drogas no forro da residência dele e, logo após, terem flagrado o réu no local, cujo prenome coincidia com o informado, vindo a apreender uma sacola contendo 76 porções de "crack", 10 porções de cocaína e 01 pedra de "crack" no interior do quarto que ele ocupava, além de 04 tijolos de maconha, 155 porções da mesma droga, 03 sacos fechados e 02 sacos abertos contendo "eppendorfs" plásticos vazios e uma balança de precisão, escondidos no forro da casa, aliados à confissão do acusado, que admitiu guardar droga para um traficante, resta certa a autoria e a destinação do entorpecente ao comércio ilícito.

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliados à apreensão de petrechos comumente utilizados para o preparo das drogas para venda e à denúncia prévia dando conta da traficância, deixam evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de

Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda.

Na hipótese, a conduta típica ter em depósito - entorpecente para fins de tráfico, isto é, para venda, distribuição ou entrega ao consumo de terceiros - ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal em comento, sendo irrelevante o fato de que o réu eventualmente não promovesse atos de venda.

3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que há processo em andamento contra o réu (autos 1501607-88.2021 da 3ª Vara Criminal local- crt. à fls. 111). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, por intermédio da aprovação da Súmula nº 444, de que inquéritos policiais e ações penais ainda em andamento não podem ser considerados para fixar a pena-base do agente acima do mínimo legal, em respeito ao princípio da não culpabilidade. Confira-se o teor da referida súmula: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”.

Anoto, porém, que a quantidade de droga encontrada é expressiva (2.957,6g de maconha e 48g de cocaína). Logo, justifica-se a fixação da pena acima do mínimo legal, o que faço em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes. De outro lado, o réu era menor de vinte e um anos à época dos fatos, razão pelo qual, reduzo a pena para o mínimo legal, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistem causas de aumento e o réu não faz jus à redução prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

A grande quantidade de droga apreendida, que evidencia que o réu não é traficante meramente ocasional, mas, ao contrário, está envolvido com atividades criminosas. Sobre o tema, decisão do C. STJ: “(...) Assim, interpretando o dispositivo legal em comento, esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado, bem como a sua natureza, constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais (...)” (Resp n. 1.344.604/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 19.12.2013).

Importa anotar que o fato de essa circunstância ter sido usada para a elevação da pena base não impede que seja usada para obstar a aplicação do redutor, porquanto se trata de consequências distintas de um mesmo fato, não havendo que se falar em bis in idem.

Nesse sentido o seguinte julgado: “(...) VIII. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas tanto na fixação da pena-base quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (...)” (STJ, HC 175747/BA, rel. Min. GILSON DIPP, j. 02/12/2010, DJe 13/12/2010).

Mais recentemente: “a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no AREn. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância

judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014)" (Habeas Corpus nº 370.057 - RO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, J. 01.12.16).

É de rigor consignar que não se está a infringir a jurisprudência com caráter de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, pois aqui a quantidade da droga e sua natureza deletéria estão sendo valoradas para agravar a pena-base e obstar o reconhecimento do "tráfico privilegiado". Situação diversa ocorreria caso a circunstância estivesse sendo utilizada também para dosar o percentual de redução previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que à evidência estaria a caracterizar o "bis in idem".

Consigno que o fato de estar guardando o entorpecente para o tráfico não beneficia o acusado, eis que não se confiaria tamanha quantidade de drogas a uma pessoa que não estivesse verdadeiramente envolvida na organização do tráfico, devendo-se destacar o alto valor de mercado das substâncias apreendidas (cf. Apelação Criminal nº 1502363-27.2019.8.26.0548).

Acrescento que a causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. O § 4º do art. 33, tem a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo não disponha o réu sinais indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo. O redutor incide na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (cf. Apelação nº 990.09.155655-6, Rel. Des. Luis Antonio Cardoso, j. 29.6.2010).

No caso dos autos, verifica-se que o réu teve passagens pela Vara da Infância pela prática de infração equiparada ao tráfico de drogas, enquanto menor, sendo-lhe imposta medida socioeducativa de liberdade assistida (autos n. 1505644-88.2019.8.26.0451 - da Vara da Infância e Juventude local - cf. certidão de fls. 124/131).

Sobre o tema, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação nº 0000491-64.2016.8.26.0125, Rel. Des. Ivan Sartori, j. 23.06.17, no qual é invocado o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos 'servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza' e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada" (HC 121509/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 29.03.2010).

Some-se a isso que o réu foi preso um mês antes dos fatos objeto do presente feito pela prática de delito da mesma espécie (cf. processo n. 1501607-88.2021 da 3ª Vara Criminal local), sendo beneficiado com a liberdade provisória, o que não permite concluir que o réu é traficante meramente ocasional e, portanto, merecedor da redução da pena.

Embora não se mostrem válidos para aferir os maus antecedentes e a reincidência, os inquéritos e processos em andamento são hábeis para não aplicar o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao

mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (EResp 1431091/SP Rel. Min. Felix Fischer j. 14/12/2016).

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena de reclusão, fixo o fechado, único compatível com a natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo. A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a perseguição criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

4. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu GUSTAVO HENRIQUE FISCHER, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial fechado e vedado o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que se manifestará no prazo legal.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Recebo o recurso interposto.

- 2) Desde já sai o Defensor intimado do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento.
 - 3) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.
 - 4) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.
 - 5) Aguarde-se a manifestação do Ministério Público e, após, tornem conclusos para deliberações.
- Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]